

1500405-41.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Fernando Angiolucci

Comarca: Ibiúna

Foro: Foro de Ibiúna

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... prisão em flagrante pelo delito de tráfico de drogas acima mencionado, foi novamente preso também pelo delito de tráfico de drogas nestes autos. Além do mais, há o convencimento também de que o réu está profundamente envolvido com o tráfico de drogas, fato revelado pela elevada quantidade de drogas (78 porções), pela diversidade destas (cocaína e maconha), pelas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibiúna

Foro de Ibiúna

2ª Vara

Praça Monsenhor Antônio Pepe, 02, Ibiuna-SP - cep 18150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500405-41.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500405-41.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2056737/2022 - DEL.POL.IBIÚNA, 23297052 - DEL.POL.IBIÚNA, 485/2022 - DEL.POL.IBIÚNA, 2056737 - DEL.POL.IBIÚNA, 485/22/505 - DEL.POL.IBIÚNA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO APARECIDO DA CRUZ DE OLIVEIRA e outro

CONFIDENCIAL

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Luiz Fernando Angiolucci

Vistos.

JULIO BARROS, qualificado às fls. 09/12, e MARCELO APARECIDO DA CRUZ DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 15/18, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, supostamente, no dia 27 de fevereiro de 2022, por volta das 13h05min, na rua Três, altura do numeral 100, Gemima - Portal Vista Linda, na cidade e Comarca de Ibiúna, previamente ajustados e mediante unidade de desígnios, traziam consigo e vendiam 69 porções de cocaína (92,1 gramas aproximadamente) e 9 porções de maconha (7 gramas aproximadamente), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Decisão às fls. 90/91, em resumo, convertendo a prisão em flagrante em preventiva.

Decisão às fls. 160, em síntese, determinando a notificação dos acusados.

Defesa do acusado Júlio de Barros às fls. 170/180.

Laudo pericial - exame químico toxicológico às fls. 186/189.

Notificação do acusado Marcelo Aparecido da Cruz de Oliveira às fls. 196 e 199.

Notificação do réu Júlio de Barros às fls. 197/198.

Defesa do acusado Marcelo Aparecido da Cruz de Oliveira às fls. 203/204.

Decisão às fls. 209/210, em resumo, recebendo a denúncia, bem como designando audiência de instrução e julgamento.

Decisão às fls. 218/223, em síntese, o réu Júlio de Barros foi considerado citado, foi indeferida a liberdade provisória formulada por este, bem como foi mantida a prisão preventiva decretada às fls. 90/92, em relação ao réu Marcelo Aparecido da Cruz de Oliveira.

Audiência de instrução às fls. 267/268, com a oitiva de três testemunhas, bem como, com o interrogatório dos acusados.

Alegações finais do D. Ministério Público, em audiência, em resumo: pleiteia a procedência da ação penal; a materialidade foi comprovada e a autoria do delito também é certa; quanto à dosimetria da pena, entende-se que a pena-base deverá ser fixada acima do mínimo legal, em relação ao réu Júlio, pois ostenta maus antecedentes, visto que além da condenação apta a configurar a reincidência, ostenta outra condenação transitada em julgado; na segunda etapa deve incidir a agravante da reincidência, em relação ao réu Júlio; na terceira etapa entende-se que não deve incidir a causa de diminuição, pois o réu Júlio é reincidente e, em relação a ambos os réus, há indícios que estavam envolvidos em atividade criminosa habitual; entende-se que o regime inicial deve ser o fechado, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; quanto ao pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa, entende-se que deve ser indeferido, pois permanecem hígidos os pressupostos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, notadamente, a necessidade de garantia da ordem pública.

Alegações finais da D. Defesa do acusado Júlio de Barros, em audiência, em síntese: pleiteia a improcedência da ação penal, visto que não ficou evidenciado, em juízo, a finalidade mercantil, o dolo, o desejo de querer negociar a droga, portanto, ausente qualquer prova sobre as elementares do crime de tráfico, constantes do artigo 33, "caput", isto é, qualquer prática, dentre as dezoito formas punitivas previstas, legalmente, a absolvição se impõe; não sendo esse o entendimento, requer a desclassificação para o artigo 28 do mesmo diploma, pois Júlio confessou que é usuário de drogas; ressalta-se que com Júlio não foi encontrado qualquer entorpecente, pois este estava em posse de Marcelo; por insuficiência probatória, com base no artigo 386, inciso VII, requer a absolvição de Júlio; caso seja entendido pela condenação, em que pese haja uma condenação pelo artigo 157, esta já ultrapassou cinco anos, não podendo ser utilizada como reincidência, não podendo haver aumento de pena; quanto ao processo pelo artigo 155, o qual Júlio está respondendo, não há trânsito em julgado, não havendo que se falar em aumento de pena; Júlio não tem ligação com organização criminosa, tecnicamente, ele é considerado primário, fazendo jus à causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas; o regime deverá ser fixado diverso do fechado; possível substituir as penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, considerando, ainda, que as drogas apresentadas eram poucas; caso se entenda pela condenação, reitera-se os pedidos de fls 257/262, concedendo a liberdade provisória, podendo ele recorrer em liberdade.

Alegações finais da D. Defesa do réu Marcelo Aparecido da Cruz de Oliveira, em audiência, em resumo: levando-se em consideração que Marcelo confessou em audiência, requer, desde já, a diminuição da pena; que seja aplicada a atenuante do artigo 65, inciso III, do Código Penal; por se tratar de réu primário, ter bons antecedentes, não ter nenhum tipo de envolvimento com a prática de organização criminosa, este preenche todos os requisitos do parágrafo 4º, do artigo 33, tráfico privilegiado; em uma possível condenação, poderá responder em liberdade; requer o regime inicial aberto, com restritiva de direitos; pleiteia, também, a liberdade provisória do réu, para que responda em liberdade até o trânsito em julgado da sentença.

Decisão às fls. 270/277, em síntese, mantendo a prisão preventiva decretada em desfavor dos acusados.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, não se verifica a citação do acusado Marcelo Aparecido da Cruz de Oliveira nos autos, contudo, este foi notificado às fls. 196 e 199, foi indicado Defensor para este réu (fls. 200), foi apresentada a resposta à acusação às fls. 203/204, seu Defensor e o acusado participaram da audiência de instrução (fls. 267/268), tendo sido o réu interrogado em juízo, sendo que foram também apresentadas suas alegações finais, Enfim, não se verifica qualquer prejuízo à defesa e não se verifica a alegação de prejuízo.

Assim, não se verificando nulidades a declarar, passo ao exame do mérito, sendo que a análise sobre a validade da diligência policial será ali analisada.

A pretensão inicial é procedente. Explico.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas restou comprovada em relação aos dois acusados em virtude do auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 02/05, auto de exibição e apreensão de fls. 21/22, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 23/24, laudo pericial exame químico toxicológico de fls. 186/189 (em síntese, ITEM 1: nove (09) porções de material contendo fragmentos vegetais de coloração esverdeada, embaladas individualmente em segmento plástico incolor (zip loc), cuja massa bruta era de 3,85g (três gramas e oitenta e cinco centigramas) e massa líquida era de 1,52g (um grama e cinquenta e dois centigramas); Resultado: detectada a presença da substância tetrahidrocannabinol (THC); ITEM 2: sessenta e nove (69) microtubos plásticos contendo material granulado de coloração amarelada, cuja massa bruta era de 91,95g (noventa e um gramas e noventa e cinco centigramas) e massa líquida era de 29,28g (vinte e nove gramas e vinte e oito centigramas); Resultado: detectada a presença da substância cocaína); bem como pelos depoimentos colhidos nos autos. Quanto à autoria, o conjunto probatório extraído dos autos comprova que os réus Júlio Barros e Marcelo Aparecido da Cruz de Oliveira praticaram a infração penal prevista no artigo 33, "caput", da Lei no. 11.343/2006, que lhes foi imputada.

Do depoimento do réu Júlio Barros, em juízo, depreende-se, em resumo: tem trinta e seis anos de idade; tem um processo de "155", que ainda está respondendo; estava trabalhando com serviços gerais antes de ser preso; sobre os fatos, informa que no dia que os policiais o abordaram no Gemima, tinha ido para comprar drogas, porque é dependente químico; estava em pé, perto do carro, a viatura veio e foi abordado; falaram que o depoente estava traficando e não estava, tinha acabado de sair do serviço, pegou dinheiro e foi comprar drogas para usar; não sabe o nome de quem estava vendendo no local, é o que foi preso com o depoente, não tinha nenhum contato com ele, não o conhecia; indagado que teria ouvido os depoimentos dos policiais, e que estes informaram que o viram encostado no veículo, conversando com o motorista, que disse que estava comprando drogas, e indagado se eles teriam inventado isso, informou que foi porque o carro parou perto do depoente, estava passando perto do carro, para comprar droga e de repente a viatura parou de frente para o carro e estava passando perto da porta do motorista, não estava parado, conversando com o motorista, este estava estacionado; sobre a condenação por roubo não falou, porque já pagou, este é de 2006, esqueceu de mencionar esse; mora na casa de sua mãe, uns cem metros do local dos fatos, onde foi preso; tanto o depoente como a testemunha do carro, que estava lá, estavam buscando drogas para uso próprio.

Em juízo, portanto, o réu Júlio Barros negou a propriedade das drogas, alegando que estava no local para comprar drogas, negando o tráfico. No entanto, sua versão não se mostra crível, não encontrando amparo nas provas produzidas nos autos.

Do depoimento do réu Marcelo Aparecido da Cruz de Oliveira, em juízo, denota-se, em síntese: tem vinte e três anos de idade; fora esse processo na Justiça Criminal já teve outro; sobre os fatos confirma que estava vendendo as drogas, estas estavam com o depoente; as drogas eram só suas, o rapaz que estava junto não tem nada a ver, era só o depoente que estava "trampando", ele foi só para buscar, também; o rapaz que está falando é o Júlio, este não estava vendendo, era só o depoente; indagado há quanto tempo estava lá, o depoente informou que estava trabalhando e acabou o gás de sua casa, pediu um dinheiro adiantado para seu patrão, este não quis adiantar o dinheiro; esse dia foi num domingo, dia vinte e sete, pegou as drogas e começou a vendê-las, para tentar conseguir o dinheiro do gás, pelo menos;

foi quando os policiais chegaram e o prenderam.

Em juízo, o réu Marcelo Aparecido da Cruz de Oliveira confirmou a propriedade dos entorpecentes, bem como o tráfico de drogas.

Em sede policial (fls. 11/12 e 17/18), os acusados optaram por permanecer em silêncio.

Do depoimento da testemunha Ricardo Gomes dos Santos, policial militar, em juízo, depreende-se, em resumo: antes dos fatos conhecia o réu Marcelo de vista; estavam em patrulhamento, conforme o programa, o bairro Gemima estava incluso e, logo no início da primeira rua, viraram à direita e surpreenderam um veículo parado, que estava negociando o valor da droga com o Júlio; Marcelo estava sentado na calçada com a sacola, a qual continha drogas e dinheiro; foram abordados, indagado o comprador, este falou que não tinha efetivado a entrega do dinheiro, mas que tinha ido comprar um pino de cocaína, não tinha dado tempo, porque a viatura chegou e os abordou; Júlio é o que estava em pé, e era o que fazia a negociação entre o Marcelo até o veículo; foram algemados, levados ao hospital e depois à delegacia; Júlio e Marcelo nada declararam; a sacola estava com o Marcelo e as drogas estavam todas lá; tinha um pouco de dinheiro com o Júlio, mas não se recorda a quantidade; Júlio é quem estava negociando a droga com o Ezequiel, que era o comprador; indagado como teria percebido que eles estavam negociando o valor da droga, se teria sido o motorista do veículo que teria dito isso, como teria chegado à essa conclusão, o depoente informou que foi indagado o motorista, e ele até mostrou o dinheiro e falou: "não cheguei a entregar, porque o senhor chegou"; ele confessou que era viciado e que iria comprar, só que não tinha a totalidade do valor, se não estiver enganado ele estava com nove reais, tinha um certo valor, do qual o depoente não se lembra o valor real do pino; acha que ele só tinha nove reais e não tinha conseguido efetivar a compra, por causa disso; ele também foi conduzido à delegacia como parte e testemunha; quando chegaram, Júlio estava encostado na porta do veículo, estava com o Ezequiel; Marcelo estava sentado na calçada, com a sacola entre as pernas; não se recorda se perguntou para o Júlio se este morava nas proximidades do local; indagado se o local dos fatos era numa esquina, o depoente informou que não ficava exatamente numa esquina, era mais para a ponta da rua, mas a hora que dobraram a esquina com a viatura, já foi possível avistá-los, as ruas ali são curtas; indagado se essa negociação que teria mencionado, se teria visto ou se foi somente o Ezequiel que teria falado, o depoente informou que no momento em que dobraram a esquina, Ezequiel se assustou e refugou, este estava com dinheiro na mão, mas não conseguiu entregar, conforme ele se assustou; não dava para ouvi-lo falando, mas ao ser entrevistado, este falou que ia comprar sim; chegaram e acabaram atrapalhando a compra; acha que ele só tinha nove reais, mas este não mencionou o valor que ia pagar, porque não era a totalidade do custo da droga que ele queria; não sabe o valor que seria a droga.

Transcreve-se do depoimento de Ricardo Gomes dos Santos, em sede policial, às fls. 06 dos autos: "... Declara que, juntamente com seu parceiro de farda realizavam patrulhamento de rotina no local dos fatos quando se depararam com três indivíduos em atitude suspeita e decidiram abordá-los. No local, foram encontradas sessenta e nove porções de substância semelhante à cocaína e nove porções de substância semelhante à maconha dentro de uma sacola, a qual era manuseada pelo senhor Marcelo, com o qual também foi encontrado o valor de R\$ 260,25. O senhor Julio, por sua vez, estava próximo a Marcelo e ao lado do veículo de Ezequiel, negociando com este o valor da venda das drogas. Que com Julio foi localizado o valor de R\$ 35,00. Indagado, o policial militar respondeu que Ezequiel sequer teve tempo de realizar a compra das drogas devido à abordagem. Explica que em conversa informal com Julio e Marcelo, ambos confessaram que estavam no local comercializando drogas, mas que não tiveram tempo de efetuar a venda para Ezequiel. ...".

Do depoimento da testemunha Wellington Salvadio Braga dos Santos, policial militar, em juízo, denota-se, em síntese: já conhecia os réus antes dos fatos, de abordagens, por conta de sua profissão; sobre a ocorrência informa que durante o patrulhamento pelo bairro do CDHU novo do Gemima, a viatura adentrou uma rua, onde avistaram um veículo e o abordado Júlio estava negociando com o indivíduo que estava de piloto no carro; a medida que a viatura se aproximou, Júlio demonstrou

uma mudança de comportamento, que motivou o Cabo Ricardo a desembarcar e realizar a abordagem; na sequência, já conseguiram segurar o Marcelo, que estava sentado uns cinco metros, com uma sacola na mão, e foi possível visualizar no interior da sacola a quantidade de entorpecentes com o Marcelo; foi conversado com o proprietário do carro, para ver qual seria o envolvimento do Júlio, este informou que estava no local para comprar drogas, estava negociando uma quantia de nove reais, que ele ia repassar para o Júlio, porém, com a abordagem, ele não teve tempo hábil de repassar esse dinheiro para o Júlio; com o Marcelo, na sacola, tinha um pouco de drogas e mais uma quantia em dinheiro; o Júlio ia pegar esses nove reais com o Ezequiel, porém não teve êxito; não se recorda se o Júlio tinha mais dinheiro; Júlio e Marcelo confirmaram para o depoente que estavam na prática de tráfico; indagado se na delegacia eles chegaram a confirmar novamente, o depoente informou que ao apresentarem a ocorrência na delegacia, o delegado já os conduziu para a cela e não tiveram mais contato com o depoimento de cada um, depois; o local é bastante conhecido como ponto de venda de drogas; indagado se chegou a questionar o Júlio se ele morava nas proximidades do local, o depoente informou que tanto o Júlio como o Marcelo moravam dentro do CDHU Gemima; informa que a testemunha Ezequiel estava entregando dinheiro para o Júlio, esta estava negociando uma situação de um entorpecente, porém, no momento da negociação, ela foi para entregar, mas não foi possível, devido a abordagem; não se recorda se foram encontrados entorpecentes com o Júlio, tendo em vista que o contato com este foi com o Cabo Ricardo e o Marcelo foi mais com o depoente; o Júlio confirmou para o Ricardo que ele estava comercializando as drogas; informa que o averiguado do carro, Ezequiel, falou, no momento, que estava negociando com o Júlio, foi ele que afirmou isso; indagado se poderia ter a noção se ele, de fato, estaria negociando com o Júlio ou se este só estava ali próximo, o depoente informou que ele estava negociando com o Júlio e o Marcelo estava nas proximidades, ambos estavam conversando; no momento que a viatura se aproximou, tanto Júlio como Marcelo demonstraram mudança de comportamento, e então o Cabo Ricardo segurou o Júlio e o depoente segurou o Marcelo, que estava sentado no chão.

O depoimento da testemunha Wellington Salvadio Braga dos Santos, em sede policial, está às fls. 07 dos autos.

Do depoimento de Ezequiel Bento de Oliveira, em sede policial, às fls. 08 dos autos, transcreve-se: "... Declara que é usuário de drogas e que havia acabado de estacionar seu veículo no local dos fatos para negociar e adquirir substâncias entorpecentes de 2 indivíduos, os quais foram posteriormente qualificados como MARCELO APARECIDO DA CRUZ DE OLIVEIRA e JULIO BARROS, os quais estavam pelo local praticando mercancia de entorpecentes. Esclarece que assim que encostou seu veículo, uma viatura da Polícia Militar encostou e realizou abordagem no declarante e nos outros 2 indivíduos, de modo que sequer teve tempo para negociar o valor das drogas, não adquirindo nenhuma droga e não entregando nenhum valor a nenhum deles. Indagado, explicou que a pessoa que se aproximou para negociar as drogas era Júlio e que a pessoa de Marcelo estava sentada em um banco mais atrás. ...".

Do depoimento da testemunha Rivaldavia Pereira Franco, em juízo, depreende-se, em resumo: não tem parentesco com os réus, conhece Júlio de Barros há dez anos; Marcelo não conhece direito, via sempre, quando ia pregar o evangelho no Gemima, mas não tinha muito contato; sobre a abordagem policial não presenciou nada; tem conhecimento que Júlio é usuário de entorpecentes.

Ora, pelas provas produzidas restou suficientemente comprovado nos autos que os réus Júlio Barros e Marcelo Aparecido da Cruz de Oliveira, na data dos fatos indicada na denúncia, previamente ajustados e mediante unidade de desígnios, traziam consigo e vendiam 69 (sessenta e nove) porções de cocaína e 9 (nove) porções de maconha. Está demonstrado pelo conjunto probatório produzido nos autos que policiais militares estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram três indivíduos: um indivíduo ao lado de um veículo, conversando com o motorista, e um outro indivíduo sentado. Efetivada a abordagem, dois indivíduos foram identificados como sendo os denunciados Marcelo e Júlio. Marcelo trazia consigo uma sacola, sendo que Júlio negociava com o terceiro indivíduo o valor da venda das drogas. Em revista pessoal, os policiais encontraram as quantias de

R\$260,05 com Marcelo e R\$35,00 com Júlio. No interior da sacola que Marcelo trazia consigo, foram encontradas as 69 porções de cocaína e as 9 porções de maconha. O indivíduo que estava no veículo foi identificado como Ezequiel, sendo que após contato, este esclareceu que ali se encontrava para a compra de entorpecentes, para seu uso pessoal, e no momento em que se encontrava negociando com Júlio a compra das drogas, a viatura se aproximou e realizou a abordagem, o que impediu a concretização da respectiva compra.

Em juízo, o réu Marcelo Aparecido da Cruz de Oliveira confessou a prática delitiva, já o acusado Júlio Barros negou a acusação.

A versão do acusado Júlio de Barros, contudo, não se mostra crível, não encontrando amparo nas provas produzidas nos autos.

O depoimento dos policiais militares, em juízo, foram seguros, coesos e harmônicos entre si, estando dotados de credibilidade e com força probatória suficiente para sustentar um decreto condenatório.

Ao lado do exposto, não se verifica dos autos qualquer indício que indicasse que os policiais militares estivessem tentando atribuir falsamente o cometimento de um delito aos réus.

No caso, restou caracterizada a traficância por parte dos réus não só pelo depoimento das testemunhas, mas, também, pela forma como as drogas, 69 porções de cocaína e 9 porções de maconha estavam acondicionadas, em embalagens individuais, prontas para a venda e para o consumo; pela elevada quantidade encontrada (total de 78 porções); diante das circunstâncias da apreensão, após abordagem dos acusados, em local conhecido como ponto de tráfico e pelo dinheiro encontrado. A alegação do réu Júlio de Barros de que estava no local, apenas para a compra de entorpecentes para seu uso, e que não estava negociando a venda destes com Ezequiel, não convence, não estando amparada por outras provas produzidas nos autos.

Portanto, o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para convencer que o réus praticaram o delito de tráfico de drogas descrito na denúncia.

Pois bem, a tipificação do crime, in casu, extrai-se da razoável quantidade de drogas apreendidas (total de 78 (setenta e oito) porções individuais), prontas para a distribuição e consumo, da diversidade de drogas (cocaína e maconha), diante das circunstâncias da apreensão, local conhecido como ponto de tráfico de drogas, além do dinheiro encontrado com ambos os réus.

Ademais, em consonância com jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde que o réu seja surpreendido no momento da realização da mercancia da droga.

Assim, não se verificando nos autos comprovação de causas excludentes de culpabilidade ou de antijuridicidade, é de rigor a condenação dos réus Júlio Barros e Marcelo Aparecido da Cruz de Oliveira pelo delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei no. 11.343/2006.

Sendo assim, passo a fixar a pena.

A) no tocante ao réu Júlio Barros

A certidão de distribuições criminais de fls. 60/63 em nome do réu Júlio revela a existência de três condenações anteriores, sendo duas pelo delito de roubo (uma sem informação de trânsito em julgado e outra com informação de trânsito em julgado), além de outra condenação por porte ilegal de arma de fogo. Contudo, inclusive diante da folha de antecedentes de fls. 77/79, não está demonstrado nos autos de forma suficiente que não teria decorrido o prazo previsto no artigo 65, inciso I, do Código Penal. Assim, não está caracterizada a reincidência do mencionado acusado.

As condenações com trânsito em julgado pelos delitos de roubo e porte ilegal de arma de fogo podem ser utilizadas para caracterizar a existência da circunstância judicial negativa mau antecedente do réu.

Observe-se, ainda, o seguinte julgado do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE. ARGUIÇÃO DE CONTRADITA DE TESTEMUNHA. ART. 214 DO CPP.

PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES PENAS DEFINITIVAS

ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE.

REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS EM CADA FASE. AGRAVO

REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. (...)

2. (...).

3. (...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do Código Penal.

5. A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço (HC n. 645.844/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021).

6. O acréscimo realizado na pena-base decorreu dos vetores negativos da culpabilidade e dos maus antecedentes, o que justifica, sem sombra de dúvidas, o percentual total aplicado (1/3). A fundamentação constou tanto da sentença proferida quanto do acórdão lavrado, que, inclusive, reduziu a pena privativa de liberdade para 07 anos, 9 meses e 10 dias. Precedentes.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 663.881/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Por outro lado, de acordo com o previsto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006: o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso concreto, a natureza diversa das drogas e a quantidade elevada destas serão utilizadas somente na terceira fase, a fim de não caracterizar o bis in idem na análise da pena.

Na primeira fase, diante do acima exposto, comprovada a existência da circunstância judicial negativa mau antecedente, com base na certidão de distribuições criminais de fls. 60/63. Sendo assim, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso legal, em razão da situação econômica do réu revelada nos autos.

Na segunda fase, nada se verificando demonstrado nos autos a justificar a alteração da pena anteriormente fixada, esta deve ser mantida.

Na terceira fase, nada se verificando como suficientemente demonstrado nos autos apto a alterar a pena anteriormente fixada, esta deve se tornar definitiva. Quanto ao redutor previsto no parágrafo 4o., do artigo 33, da Lei no. 11.343/2006, a legislação permite apenas a redução se o agente não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa, além de ser primário e possuir bons antecedentes. No caso dos autos, há o convencimento de que o réu Júlio Barros estava se dedicando às atividades criminosas, conforme certidão de distribuições criminais de fls. 60/63, em nome do réu, que revela a existência de três condenações anteriores, sendo duas pelo delito de roubo (uma sem informação de trânsito em julgado e outra com informação de trânsito em julgado), além de outra condenação por porte ilegal de arma de fogo. Além do mais, há o convencimento também de que o réu está envolvido com o tráfico de drogas, fato revelado pela elevada quantidade de drogas (78 porções), pela diversidade destas (cocaína e maconha), pelas circunstâncias de sua apreensão, local conhecido como ponto de tráfico de drogas, além do que estava agindo em concurso de pessoas. Sendo assim, tais fatos revelam a total incompatibilidade da aplicação do redutor previsto no parágrafo 4o., do artigo 33, da Lei no. 11.343/2006, no caso dos autos, para o réu Júlio Barros. Portanto, não restou comprovado nos autos que o réu preenche os requisitos do parágrafo 4o., do artigo 33, da Lei no. 11.340/2006.

B) No que diz respeito ao réu Marcelo Aparecido da Cruz de Oliveira

Em conformidade com a súmula no. 444 do C. STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Continuando, observa-se que anteriormente aos fatos destes autos, conforme certidão de distribuições criminais de fls. 64/65 e FA de fls. 75/76, o réu Marcelo Aparecido da Cruz de Oliveira foi preso em flagrante delito acusado da prática do delito de tráfico de drogas, tendo sido concedida a este a liberdade provisória. Consultando os referidos autos, observa-se condenação em 21/03/2022 pelo delito de tráfico de drogas, com trânsito em julgado. Contudo, considerando que o trânsito em julgado foi posterior ao fato destes autos, o réu não pode ser considerado reincidente, bem como, tal condenação não caracteriza mau antecedente, bem como frente à súmula no. 444 do C. STJ, não pode servir para agravar a pena-base. Por outro lado, de acordo com o previsto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006: o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso concreto, a natureza diversa das drogas e a quantidade elevada destas serão utilizadas somente na terceira fase, a fim de não caracterizar o bis in idem na análise da pena.

Assim, na primeira fase, nada mais se verificando demonstrando nos autos apto a majorar a pena-base, fica esta fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal, diante da situação econômica do réu revelada nos autos.

Na segunda fase, verifica-se presente a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal) que não pode servir para diminuir a pena abaixo do mínimo legal nesta fase, em conformidade com a súmula no. 231 do C. STJ.

Na terceira fase, nada se verificando como suficientemente demonstrado nos autos apto a alterar a pena anteriormente fixada, esta deve se tornar definitiva. Quanto ao redutor previsto no parágrafo 4o., do artigo 33, da Lei no. 11.343/2006, a legislação permite apenas a redução se o agente não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa, além de ser primário e possuir bons antecedentes. No caso dos autos, há o convencimento de que o réu Marcelo Aparecido da Cruz de Oliveira estava se dedicando às atividades criminosas, conforme certidão de distribuições criminais de fls. 64/65 e FA de fls. 75/76, posto que o réu Marcelo Aparecido da Cruz de Oliveira foi preso em flagrante delito acusado da prática do delito de tráfico de drogas, tendo sido concedida a este a liberdade provisória. Consultando os referidos autos, observa-se condenação em 21/03/2022 pelo delito de tráfico de drogas, com trânsito em julgado. Contudo, considerando que o trânsito em julgado foi posterior ao fato destes autos, o réu não pode ser considerado reincidente, bem como, tal condenação não caracteriza mau antecedente. No entanto, como mencionado, há o convencimento de que o réu estava se dedicando às atividades criminosas, posto que cerca de pouco mais de 7 (sete) meses e algumas semanas depois da prisão em flagrante pelo delito de tráfico de drogas acima mencionado, foi novamente preso também pelo delito de tráfico de drogas nestes autos. Além do mais, há o convencimento também de que o réu está profundamente envolvido com o tráfico de drogas, fato revelado pela elevada quantidade de drogas (78 porções), pela diversidade destas (cocaína e maconha), pelas circunstâncias de sua apreensão, local conhecido como ponto de tráfico de drogas, além do que estava agindo em concurso de pessoas. Sendo assim, tais fatos revelam a total incompatibilidade da aplicação do redutor previsto no parágrafo 4o., do artigo 33, da Lei no. 11.343/2006, no caso dos autos, para o réu Marcelo Aparecido da Cruz de Oliveira. Portanto, não restou comprovado nos autos que o réu preenche os requisitos do parágrafo 4o., do artigo 33, da Lei no. 11.340/2006. Do regime de cumprimento inicial de pena, substituição da pena privativa de liberdade e suspensão condicional de pena.

Para os dois réus, diante da quantidade de pena aplicada e do previsto no artigo 33 do Código Penal, o regime inicial semiaberto é o único que se mostra suficiente para o presente caso, para reprovação e prevenção do crime.

No mais, inaplicável, no caso, para os dois réus, o parágrafo 2o., do artigo 387, do CPP, de plano, diante da quantidade de penas aplicada e do tempo das prisões preventivas.

O tráfico de drogas de qualquer dimensão é um crime de exagerada periculosidade

social, pois fomenta a prática de outros crimes, além da trágica e destruidora repercussão social familiar que traz inevitavelmente.

No caso dos autos, restou comprovado que os réus estavam trazendo consigo e vendendo um total de 78 (setenta e oito) porções de drogas, maconha e cocaína, sendo esta última devastadora para a saúde dos usuários.

Sobre a lesividade da droga cocaína, observem-se os ensinamentos constantes do julgado do E. TJSP abaixo transcrito:

"...

4. A respeito da lesividade da substância apreendida, como mui bem exposto pela Colenda Nona Câmara Criminal (Apelação Criminal nº 0066735-11.2013.8.26.0050, Comarca da Capital, Rel. o eminente Des. Penteado Navarro, j. em 08 de maio de 2014), em termos de efeitos adversos (intoxicação) das substâncias (drogas ou fármacos) sobre o organismo humano tem-se que, ainda no século XIV, Paracelsus "definiu que a diferença entre o medicamento e o veneno encontra-se na dose" (apud Marcos Passagli, Toxicologia Forense, 3ª ed., Millennium, 2011, cap. I, nº 1, pág. 3).

Quanto aos produtos da coca (erythroxilin), cocaína em pó e o derivado em pedra (base livre ou crack), a quantidade pode ser mensurada com parâmetro em overdoses (doses insuportáveis ou excessivas para alguém). Com o emprego desse dado pode ser verificada a desproporção entre o uso próprio exclusivo e o consumo por outros indivíduos (terceiros).

Segundo a literatura médica e a jurisprudência, a reação letal ou não letal em usuários diversos, por intoxicação aguda, da cocaína com a pureza da rua (depois de modificada ou "batizada"), depende de muitos aspectos. Doses consideradas pequenas, de alguns centigramas, entre 0,01 e 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (vide Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, nº 14.2.11.3, pág. 636; Guilherme Oswaldo Arbenz, Medicina Legal e Antropologia Forense, 1ª ed., Atheneu, 1988, nº 42, pág. 539; Marcos Passagli, Toxicologia Forense, 3ª ed., Millennium, 2011, cap. V, nº 1.3.2, pág. 140; STJ, 5ª T., HC nº 235.257/DF, Rel.ª Min.ª Marilza Maynard, DJe de 26/03/2013).

Note-se, por oportuno, que "A cocaína fumada na forma de crack... possui ação farmacológica comparável à cocaína" (v. a citada obra Toxicologia Forense, cap. V, nº 1.3.1, pág. 136).

Logo, aprendidos 130,6 gramas de cocaína, com a sua divisão por doses de 0,02g, teremos no mínimo cerca de 6.530 quantidades letais (excessivas ou insuportáveis) para cada usuário do tóxico. Até porque o consumo continuado de cocaína (também denominada pelos viciados de "pó" ou "farinha") provoca o "enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação" (vide Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82).

..." (Agravado de Execução Penal nº 7001829-94.2014.8.26.0198, da Comarca Franco da Rocha).

Desta forma, além da exagerada periculosidade social do tráfico de drogas, por fomentar a prática de outros crimes, e da trágica e destruidora repercussão social familiar que traz, no caso específico dos autos, verifica-se presente a periculosidade dos réus, pois escolheram o tráfico de drogas para a obtenção de ganhos financeiros em detrimento da saúde dos usuários, escolhendo o tráfico da substância cocaína, devastadora para a saúde dos usuários, em quantidade suficiente para um exacerbado prejuízo da saúde de um elevado número de pessoas.

Assim, diante do acima exposto, das penas aplicadas, inclusive, no tocante ao réu Júlio Barros, das condenações anteriores com trânsito em julgado, consoante acima discriminado, não se mostra cabível, no caso, a substituição das penas aplicadas por restritivas de direitos. Quanto ao réu Marcelo Aparecido da Cruz de Oliveira, diante do acima exposto, das penas aplicadas e do convencimento de que estava se dedicando às atividades criminosas, também não se mostra cabível, no caso, a substituição das penas aplicadas por restritivas de direitos.

A suspensão condicional da pena, em virtude da quantidade das penas aplicadas, bem como das razões acima expostas quanto à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quanto aos dois réus, também não

se mostra possível.

Do direito de recorrer em liberdade.

Nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, tendo em vista a condenação pelo crime de tráfico de drogas, pois responderam ao processo presos e por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, ressaltando-se que esta se justifica para garantir a ordem pública, diante da periculosidade dos réus reveladas pelos fatos acima descritos, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, diante da pena aplicada e do regime fixado. A periculosidade dos réus estão evidenciadas, no caso, pois visando ganhos financeiros, deixaram de considerar o impacto negativo dos entorpecentes na saúde dos usuários, em especial da cocaína, pela alta lesividade desta, ficando demonstrado o desprezo pela vida, ressaltando-se ainda a elevada quantidade de drogas encontradas com o réus (total de 78 porções: maconha e cocaína). Acrescente-se que no tocante ao réu Júlio Barros, verifica-se, ainda, a existência de condenações anteriores com trânsito em julgado, conforme certidão de distribuições acima mencionada, restando o convencimento de que estava se dedicando às atividades criminosas, fato que demonstra a sua periculosidade e a necessidade de garantir a ordem pública. Quanto ao réu Marcelo Aparecido da Cruz de Oliveira há o convencimento de que estava se dedicando às atividades criminosas, conforme certidão de distribuições criminais de fls. 64/65 e FA de fls. 75/76, posto que referido réu foi preso em flagrante delito acusado da prática do delito de tráfico de drogas, tendo sido concedida a este a liberdade provisória, e pouco mais de 7 (sete) meses e algumas semanas, voltou a ser preso em flagrante nestes autos pelo delito de tráfico de drogas (com elevada quantidade de drogas, diversidade, dinheiro razoável e agindo em concurso de agentes). Tais fatos revelam a periculosidade deste réu também e a necessidade de garantir a ordem pública.

Assim, há a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade dos réus comprovadas nos autos.

E mais, "a despeito do princípio da presunção da inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda instrução criminal". (STJ-HC nº 62.175-SP-5ª- Rel Ministra Laurita Vaz- J.02.10.2008- DJe 28.10.2008).

Dispositivo.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação penal para:

- A) CONDENAR o réu J.B., acima indicado e qualificado às fls. 09/12 dos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade correspondente a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso legal, com correção monetária no momento da execução, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei no. 11.343/2006.
- B) CONDENAR o réu M.A.C.O., acima indicado e qualificado às fls. 15/18 dos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade correspondente a 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal, com correção monetária no momento da execução, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei no. 11.343/2006.

Custas na forma da lei.

Expeça-se o necessário, inclusive guias de execução provisória.

Oportunamente:

Expeça-se guias de execução definitiva;

Oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação dos réus, com a devida identificação, para o cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

Oficie-se ao órgão estatal de cadastro de dados sobre antecedentes, fornecendo informações sobre a condenação dos réus.

Traga a Serventia para os presentes autos a certidão de objeto e pé do outro processo indicado na certidão de distribuições criminais de fls. 64/65 de Comarca diversa.

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo (fls. 200), em conformidade com o estabelecido no convênio entre a OAB e a DPE, para o presente caso.

Encaminhe-se cópia da presente sentença a fim de instruir os autos de Habeas Corpus (fls. 282/300).

P.R.I.C.

Ibiuna, na data da assinatura digital.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA